

1500161-37.2022.8.26.0592

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA

Comarca: Tupã

Foro: Foro de Tupã

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/08/2022

... que se falar em condenação pelo crime de tráfico, todavia, justifica-se a desclassificação para o art. 28, da lei 11.343 /06.

Pode-se aplicar a desclassificação do crime de tráfico para uso quando o conjunto probatório deixa dúvidas quanto à existência de materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas.

No caso em tela, o acusado mantinha em posse 01 (uma) ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tupã

Foro de Tupã

Vara Criminal

Rua Colômbia, 200, . - Jardim América

CEP: 17605-900 - Tupã - SP

Telefone: (14) 3496-8033 - E-mail: tupacr@tjsp.jus.br

1500161-37.2022.8.26.0592 - lauda

C O N C L U S ã O

Em 30 de agosto de 2022 faço conclusão destes autos ao(à) Exmo(a). Sr(a). Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA, MM. Juiz(a) de Direito.

SENTENÇA

Processo nº:

1500161-37.2022.8.26.0592

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SERGIO LAURINDO DOS SANTOS

Vistos.

O Ministério Público ofereceu denúncia em face de SÉRGIO LAURINDO DOS SANTOS por supostamente ter praticado os fatos descritos na denúncia:

“Consta do incluso inquérito policial que no dia 01 de março de 2022, por volta das 04h30min, na Estrada Vicinal Tupã Universo, KM 543, distrito de Universo, nesta cidade e comarca de Tupã, o denunciado, já qualificado, tinha em depósito, 01 (uma) porção de cocaína, em forma de crack, com peso líquido de 32,0 gramas (peso bruto 43,13g) e 02 porções de cocaína, com peso líquido de 80,58grams (peso bruto 93,77), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 20/21; laudo de constatação provisória de substância entorpecente de fls. 23/25 e laudo definitivo a fls. 115/120).

Segundo se apurou o denunciado promovia o tráfico de entorpecentes nesta cidade de Tupã, e, para tanto, as drogas eram adquiridas de fornecedor não identificado, e destinadas ao consumo de terceiros.

Ocorre que na ocasião dos fatos policiais militares foram até ao local descrito acima porque o automóvel do denunciado estava pegando fogo.

Os militares perguntaram para o denunciado se havia mais alguém na residência, quando ele disse que morava sozinho e acabou admitindo que possuía drogas em sua residência.

Ato contínuo, um dos militares, ainda do lado de fora do imóvel, visualizou em cima de uma mureta de madeira na área externa do imóvel uma pedra com características de "crack" e ao lado, dentro de um chapéu preto, duas porções de cocaína e um pote plástico contendo em seu interior vários saquinhos plásticos recortado característicos de embalagens de drogas e uma balança de precisão.

As drogas foram apreendidas (fls. 20/21) e submetidas a laudo de constatação (fls. 23/25).

Observa-se que a diversidade e forma de acondicionamento das drogas, a balança de precisão de apreendida, os petrechos para embalar drogas (saquinhos plásticos recortados), assim como as demais circunstâncias, são elementos indicativos de que investigado promovia o comércio ilícito de entorpecentes.

O réu foi preso em flagrante, sendo convertida a prisão preventiva (fls.58).

A denúncia foi recebida em 15/06/2022 fls.163.

Devidamente citado, o réu apresentou resposta à acusação. Não foi concedida absolvição sumária.

Na audiência de instrução e julgamento, nesta data, foram ouvidas as testemunha(s), sendo, após, interrogado o réu.

Na fase do artigo 402 do CPP, as partes nada requereram.

Em alegações finais orais o Ministério Público requereu a condenação, com aplicação da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, e a Defesa pugnou pela desclassificação para o crime de uso.

Após alegações finais orais gravadas via audiovisual, passei à sentença.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Presentes os pressupostos processuais, bem como as condições da ação, e não havendo nenhuma nulidade a ser sanada de ofício, passo ao exame do mérito.

No mérito, a ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade resta-se comprovada por meio do termo de ocorrência; auto de prisão em flagrante; auto de exibição e apreensão; laudo pericial; bem como pela prova oral colhida em Juízo.

A autoria delitiva também resta-se demonstrada, sobretudo pela prova oral colhida em Juízo.

A testemunha ELCIO JOSÉ BERTHOLDO, policial militar, em seu depoimento judicial, relatou que foram acionados para prestar apoio ao Corpo de Bombeiros em razão de incêndio em um veículo. O Bombeiro disse que estava sendo impedido de realizar o serviço, pois o réu estava agressivo. O réu concordou e autorizou. O réu confessou que possuía drogas na residência. Viram que em cima de um muro tinha uma pedra de crack. Ao lado, também havia um chapéu com um pó branco no interior. Encontraram uma balança de precisão. Não conhecia o réu de outras ocorrências. A chácara fica distante da cidade. Acredita que não havia movimentação de pessoas perto do local. Não apreenderam dinheiro. Entraram na casa em razão da visualização da droga, uma vez que havia situação de flagrância. Acredita que no local não era ponto de venda de drogas.

A testemunha JESIMIEL DOS SANTOS, policial militar, em seu depoimento judicial, relatou que foram no local auxiliar o Corpo de Bombeiros, uma vez que havia um incêndio no carro do réu. Este não estava deixando os bombeiros apagarem o fogo. O réu disse que morava sozinho. Viram, em um muro, uma pedra de crack. O réu confessou e disse que tinha mais drogas. O réu autorizou a entrada. Atrás do muro, dentro de um chapéu, tinha um saco de pó branco. Não entraram na casa, em si. Só foram na área externa. Não conhecia o réu. O local não era conhecido como ponto de venda de drogas. Não encontraram dinheiro. O próprio réu disse que havia droga na casa.

Outrossim, nem se diga que os depoimentos prestados pelos Policiais Militares são indignos ou suspeitos de credibilidade, eis que não possuem motivo algum para incriminar falsamente o denunciado. Além disso, nada há nada de concreto nos autos que pudesse desmerecer essa prova. Assim já se manifestou o Colendo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 73518/SP, 1ª T., Relator Ministro Celso de

Mello, j. 26/03/96, Dje 18/10/96). Ademais, a Suprema Corte firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de os policiais que participaram das diligências ou da prisão em flagrante serem ouvidos como testemunha. (RHC 108.586, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 9-8-2011, 1ª T, DJE de 8- 9-2011). No mesmo sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça: Habeas Corpus 223086/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, j. em 19/11/2013. É neste mesmo sentido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: TJ-SP - APL: 00128093120148260196 SP 0012809-31.2014.8.26.0196, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 06/12/2016, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/12/2016; TJ-SP - APR: 00000257420178260274 SP 0000025-74.2017.8.26.0274, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 29/10/2020, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/10/2020.

A testemunha de Defesa Elza Maria Rodrigues dos Santos, em seu depoimento judicial, disse que não sabe nada sobre os fatos. Se limitou a tecer comentários sobre o caráter do réu. Disse que a estrada não é movimentada, quase não passa ninguém. Não ia ninguém na casa do réu. Este estava sempre sozinho.

Interrogado judicialmente, o réu confessou, em parte, os fatos. Disse que tinha acabado de se separar de sua esposa e, em razão disso, passou a usar drogas. Estava se sentindo sozinho. Nunca vendeu drogas. É usuário de cocaína e maconha.

Do percuciente do quadro probatório, infere-se que a conduta do acusado melhor se amolda ao delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006, inexistindo prova segura e concludente da finalidade da traficância, devendo vigorar, no caso, o princípio do in dubio pro reo. Com efeito, o conjunto probatório é insuficiente para reconhecer a finalidade da mercancia.

A materialidade do delito restou comprovada, mas constatada a ausência de provas quanto a versão acusatória, que se contrapõe com a firme alegação da processada no sentido de que a droga servia ao seu consumo, não há que se falar em condenação pelo crime de tráfico, todavia, justifica-se a desclassificação para o art. 28, da lei 11.343 /06.

Pode-se aplicar a desclassificação do crime de tráfico para uso quando o conjunto probatório deixa dúvidas quanto à existência de materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas.

No caso em tela, o acusado mantinha em posse 01 (uma) porção de cocaína, em forma de crack, com peso líquido de 32,0 gramas e 02 (duas) porções de cocaína, com peso líquido de 80,58 gramas, conforme autos de exibição e apreensão de fls. 20/21. O laudo pericial de fls.115/120 mostram as substâncias dos entorpecentes. Todavia, os policiais apenas tiveram conhecimento acerca da droga, uma vez que foram até o local em razão do automóvel do réu estar pegando fogo.

Não havia nenhuma investigação acerca do réu estar praticando o tráfico de drogas. Ademais, o réu tem quase 60 anos de idade e nunca respondeu a ação penal por tráfico de drogas (fls. 34/36).

Não se pode olvidar que ao decreto condenatório não basta um mera probabilidade, mas um juízo de certeza, demandando-se provas seguras ou sérios indícios acerca da autoria delitiva. De fato, não restou provada nos autos a prática da mercancia ilícita. Circunstância que, aliada à negativa da traficância da acusada desde a fase policial, amparada pelas demais provas, torna impossível o decreto condenatório baseado em inferências e suposições para a imputação do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Reprisa-se, ainda, que o delito de tráfico de drogas é geralmente perpetrado na clandestinidade, devendo a autoridade policial e seus agentes desenvolver as ações necessárias à constatação e recolhimento de provas que possam sustentar uma condenação, sendo certo que na ausência de caderno probatório substancial, melhor é adotar o princípio do in dubio pro reo, preservando-se as garantias constitucionais insertas nos princípios da presunção de inocência e da não culpabilidade. Ademais, é cediço que a quantidade de substância entorpecente ilícita apreendida pode ser considerada para a formação do juízo de valor quanto à existência ou não do crime de tráfico, já que muitas vezes não se consegue flagrar o ato mercantil. Contudo, no caso em tela, a pequena quantidade de substância entorpecente encontrada, o local onde a droga estava escondida e a falta de

variedade, autoriza crer que a versão exculpatória da defesa é verossímil, consubstanciada na tese de que a droga seria para consumo próprio. Por certo, a linha que diferencia as condutas previstas nos artigos 28 e 33 da Lei 11.343/2006 é tênue. Nesse contexto, o legislador, ao redigir o § 2º do retromencionado art. 28, indicou ao intérprete critérios objetivos e subjetivos para determinar, no caso concreto, a correta subsunção do comportamento do agente: "§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente."

Repisa-se, não foi encontrada nenhuma outra prova (anotações referentes ao tráfico, grande quantidade de dinheiro em espécie e em notas pequenas, testemunhas oculares da venda de drogas, prisão em flagrante durante a venda etc.) que pudesse corroborar a imputação pela prática do tráfico de drogas pelo acusado.

Por fim, necessário esclarecer: "vigora no sistema processual penal brasileiro, o princípio do livre convencimento motivado, em que o magistrado pode formar sua convicção ponderando as provas que desejar" (STJ, HC 68.840/BA, rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 28-04-2015).

Por outro lado, não há como ignorar que a materialidade do delito ficou comprovada através dos autos de exibição e apreensão, do laudo de constatação, bem como do laudo de exame químico toxicológico. Porém, diante do escasso conjunto probatório reunido nos autos, verifica-se que permanece séria dúvida de que a réu é efetivamente traficante e que as poucas porções encontradas em seu poder destinavam-se ao comércio ilícito.

Vejamos o ensinamento de Guilherme de Souza Nucci (Leis penais e processuais penais comentadas – 8. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014):

"As cinco condutas previstas no art. 28 (adquirir, guardar, ter em depósito, transportar e trazer consigo) também fazem parte do art. 33 (antigo art. 12 da Lei 6.368/76). Entretanto, neste último caso, cuida-se de tráfico ilícito de entorpecentes, crime equiparado a hediondo, gerando pena de reclusão, de 5 a 15 anos, e multa elevada, enquanto o outro não constitui delito equiparado a hediondo, sem a possibilidade de aplicação de pena privativa de liberdade, somente porque a finalidade do agente é o consumo pessoal. Em face disso, muitos traficantes buscam, como meio de defesa, a desclassificação da infração penal da figura do art. 33 (antigo art. 12 da Lei 6.368/76) para o tipo do art. 28 (antigo art. 16 da Lei 6.368/76). Por outro lado, inúmeros usuários acabam, injustamente, autuados com base no art. 33 (antigo art. 12 da Lei 6.368/76), quando merecem a desclassificação para o art. 28 (antigo art. 16 da Lei 6.368/76). Essa situação não comporta resolução teórica única, pois depende do caso concreto e das provas produzidas em cada processo. Porém, tem sido referencial para a jurisprudência brasileira a quantidade da droga apreendida, os antecedentes criminais do agente, quando voltados ao tráfico, bem como a busca do caráter de mercancia. Quem traz consigo grande quantidade, já foi condenado anteriormente por tráfico e está em busca de comercialização do entorpecente é, com imensa probabilidade, traficante (art. 33). No entanto, aquele que possui pequena quantidade, nunca foi antes condenado por delito relativo a tóxicos, bem como não está comercializando a droga é, provavelmente, um usuário (art. 28).

Não havendo provas de efetiva realização de atos que o réu tinha a intenção de comercializar a substância entorpecente, não há que se falar em crime de tráfico de drogas. Assim, devida, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de uso.

Há precedentes do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo neste sentido: APR: 15006112120188260559 SP 1500611-21.2018.8.26.0559, Relator: Osni Pereira, Data de Julgamento: 30/04/2021, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 30/04/2021; APL: 00425368720148260114 SP 0042536-87.2014.8.26.0114, Relator: Osni Pereira, Data de Julgamento: 07/03/2017, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/03/2017; APR: 15117210620198260228 SP 1511721-06.2019.8.26.0228, Relator: Osni Pereira, Data de Julgamento: 30/04/2021, 16ª Câmara de Direito

Criminal, Data de Publicação: 30/04/2021; APR: 15007932920198260411 SP 1500793-29.2019.8.26.0411, Relator: Paulo Rossi, Data de Julgamento: 16/04/2021, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 16/04/2021.

Com relação à medida aplicada, verifico que o réu está preso desde o dia 01/05/2022, ou seja, totalizando quase 4 meses. Ademais, as medias previstas no artigo 28 da Lei de Drogas somente podem ser aplicadas pelo prazo máximo de 10 meses, em caso de reincidência, conforme § 4º do referido artigo.

Destarte, nos termos do artigo 28, inciso I, da Lei de Drogas, aplico ao réu a medida educativa de ADVERTÊNCIA sobre os efeitos das drogas, atendendo as circunstâncias do caso.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva para DESCLASSIFICAR a imputação, do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 para o art. 28, caput, da Lei 11.343/06, e, em consequência, aplico ao réu a medida educativa de ADVERTÊNCIA sobre os efeitos das drogas, atendendo as circunstâncias do caso. Fica o sentenciado advertido sobre os efeitos das drogas, no presente ato. Assim, julgo extinta a pena pelo cumprimento.

REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA. Expeça-se alvará de soltura colocando-se o réu em liberdade, salvo se estiver preso por outro motivo.

Oficie-se ao IIRGD.

Oficie-se à Autoridade Policial de origem autorizando a destruição do restante da droga apreendida, se for o caso.

Sem custas.

P.R.I.

Tupã, 30 de agosto de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA